

0002091-44.2019.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002091-44.2019.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002091-44.2019.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CLEBER OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de LEONARDO CLEBER OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 171, por centenas de vezes, na forma do topo dos art. 29 e art. 71, todos do Código Penal, afirmando que em diversas datas do segundo semestre do ano de 2011, na Rodovia SP 215, Km 98, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, agindo em concurso e com unidade de desígnios com HÉLIO BERNARDINO DE OLIVEIRA, obtiveram para si, aproximadamente R\$300.000,00 em prejuízo da empresa Travagin e Travagin Ltda., induzindo e mantendo em erro seu supervisor Sérgio Luiz Fernandes Coimbra, além dos sócios-proprietários, mediante meio fraudulento consistente em utilizar o cadastro de 65 clientes para realizar compras para si mesmos e, após, revender os produtos a preço inferior.

Segundo narrou denúncia (fls. 1024/1027), "HELIO e LEONARDO atuavam como prestadores de serviços da empresa "Travagin e Travagin Ltda." nas funções de representante comercial, o primeiro, e motorista, o segundo, com atuação na região de Ituiutaba/MG. Devidamente conluiados, HELIO, com amplo acesso ao sistema de

dados da empresa-vítima, utilizou, sem autorização, o cadastro de 65 (sessenta e cinco) clientes, fazendo-se passar por eles para efetuar compras cujo destinatário era ele mesmo e, então, revenderia as mercadorias por valores muito aquém ao de mercado. Visando evitar que os clientes que tiveram seus dados fraudulentamente usados recebessem cópia das notas fiscais dos produtos adquiridos em seus nomes, HELIO alterou o endereço eletrônico destes no sistema. LEONARDO, por sua vez, fazia a entrega dos produtos nos endereços indicados por HELIO sem relatar qualquer irregularidade à sua empregadora, sendo certo que, como motorista, também deveria conferir a idoneidade das vendas, cabendo a ele, no ato da entrega, conferir as notas fiscais, produtos e dados e endereço do comprador, colhendo o aceite deste (comprovante do recebimento), o qual era adulterado por ele para que o golpe não fosse descoberto, já que entregava os objetos para pessoas e locais diversos do que constava nas notas, conforme a ele repassado por HELIO. Todavia, desconfiado da atuação dos denunciados em razão do crescente volume de clientes inadimplentes na região Ituiutaba/MG, Claudinei Travagin, sócio-proprietário da empresa-vítima, pediu para Sérgio, supervisor de vendas, verificar a situação, tendo, então, sido descobertos os crimes. Em conversa com HELIO, este confessou a Sérgio a prática dos crimes, entregando-lhe diversos documentos, dentre eles notas fiscais e duplicatas em aberto, indicando, ainda, Rafael Vinicius Borges, como um dos compradores dos produtos fraudulentamente adquiridos, com quem, então, foi reavida pequena parte da mercadoria desviada, conforme demonstram as fotografias de fls. 28/31. Ouvido em solo policial, HELIO confessou a prática reiterada dos crimes (fls. 62/63). Todos os débitos fraudulentamente constituídos em nome dos clientes da empresa-vítima foram por esta assumidos, absorvendo, portanto, todo o prejuízo decorrente das condutas delitivas dos denunciados".

A denúncia foi oferecida em 10/10/2019 (fls.1024/1027), recebida em 11/10/2019 (fls. 1028/1030); o réu Leonardo foi citado às fls. 1132/1333 e apresentou resposta à acusação às fls. 1201/1217. Audiência de instrução (fls. 1820/1827), tendo o MP apresentado alegações finais naquela oportunidade; a defesa, a pedido, apresentou memoriais escritos (fls. 1852/1859).

Em relação a Hélio o feito foi desmembrado por decisão de fls. 1286/1287.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 171 do Código Penal assim descreve o delito de estelionato:

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento

O tipo objetivo consiste na conduta de obter vantagem ilícita, de cunho econômico, beneficiando a si ou a outrem com prejuízo da vítima, por meio da falsa percepção da realidade de alguém (que não necessariamente precisa ser a vítima do prejuízo), induzida ou mantida pelo agente, que atua com artifício (encenação material), ardil (conversa enganosa) ou outro meio fraudulento (que pode, inclusive, ser o silêncio). O tipo subjetivo apresenta elemento específico, a finalidade de lucro indevido.

O estelionato é crime de duplo resultado consumando-se no primeiro momento em que se pode atestar simultaneamente a obtenção da vantagem indevida e do prejuízo. A reparação do dano, exceto no caso do cheque sem fundo, não afasta a configuração do estelionato, mas pode servir como causa de diminuição (art. 16) ou atenuante (art. 65, III, "b").

No caso em exame, há prova da existência e da autoria do delito.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 54), documentos de fls. 214/530, 532/733, 735/1020 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Claudinei Travagin, representante do estabelecimento, na fase policial, disse que "é sócio-proprietário da empresa TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA, sendo que a pessoa de HÉLIO BERNARDINO DA SILVEIRA era seu representante comercial na região de Ituiutaba-MG, sendo que ele começou a utilizar o cadastro de clientes da empresa para efetuar compras; informa que ao invés de serem entregues nas empresas, eram entregues diretamente a HÉLIO, com a conivência do motorista responsável pelas entregas, LEONARDO CLEBER OLIVEIRA; informa que no início as mercadorias estavam sendo pagas corretamente, mas eram utilizados cadastros dos clientes e em muitas vezes as mercadorias eram entregues para a pessoa de RAFAEL, filho do proprietário do SUPERMERCADO IDEAL; informa que devido ao volume de vendas de isqueiros Max Bic, cartela com 12 e outros modelos, o declarante levantou suspeita e resolveu entrar em contato com os clientes para saber se estavam recebendo os produtos; informa que HÉLIO alterou o endereço eletrônico dos clientes, para que não recebessem as cópias das notas fiscais de compra dos produtos, por isso os clientes não recebiam as cópias das notas fiscais eletrônicas; informa que fez contato com o supervisor, SÉRGIO, e pediu para que fizesse o monitoramento, com isso ele constatou que muitos clientes que HÉLIO tinha efetuado vendas estava com o atraso de pagamento, onde HÉLIO confessou que estava desviando as mercadorias; informa que SÉRGIO descobriu através das informações prestados por HÉLIO, que as mercadorias estavam sendo entregues para RAFAEL; informa que após HÉLIO confessar o fato, ele telefonou para RAFAEL para informar a quantidade de caixas que estava em seu poder, o qual solicitou um tempo para a contagem; informa que durante este tempo SÉRGIO e HÉLIO, foram até a cidade de Monte Alegre de Minas, no qual foi constatado na casa de RAFAEL que havia 109 caixas de isqueiros; informa que SÉRGIO entrou em contato com o declarante, o qual mandou um caminhão para recolher a mercadoria; informa que a princípio foi constatado que HÉLIO vendia a R\$ 360,00 cada caixa de isqueiro, sendo que a empresa vendia na faixa de R\$ 500,00; informa que após descoberto HÉLIO entregou ao supervisor diversos documentos, notas fiscais, duplicatas pagas e em aberto; informa que seu prejuízo é de cerca R\$ 150.000,00; informa que após o levantamento das notas fiscais ficou constatado que no golpe eram desviados diversos produtos, tais como papel sulfite, pen drive, canetas esferográficas, fitas de empacotamento, fita crepe, ou seja, produtos escolares e Office, além dos isqueiros; informa que as mercadorias eram desviadas da empresa, durante a entrega, sendo que o motorista era conivente com todo o golpe aplicado por HÉLIO, tendo em vista a obrigação do motorista no ato da entrega conferir com a nota fiscal, produtos e entrega-los ao comprador certo, ao endereço eletrônico; informa que o aceite da mercadoria era de responsabilidade do motorista colher do comprador, mas esses canhotos eram adulterados; informa que em conversa com RAFAEL, este disse que comprava as mercadorias de HÉLIO, por um preço bem abaixo do mercado, pois ele dizia que comprava as mercadorias em seu CPF, sendo que tal prática é uma forma de RAFAEL sonegar impostos, pois compra as mercadorias, por um preço vil e sem documentos; informa que entrou em contato com RAFAEL e HÉLIO pedindo para eles entregarem o restante das mercadorias desviadas, as quais não foram entregues; esclarece que foram usados cadastros de sessenta e cinco clientes para a ação; informa que irá apresentar as cópias dos documentos relativos ao fato para encaminhamento a Delegacia de Polícia que apura os fatos". Em juízo manteve sua versão. Hélio era o representante em Ituiutaba e Leonardo era o motorista terceirizado. Naquele período surgiram vendas irregulares; o principal produto era o isqueiro Bic; especialidade do negócio é papelaria; pediu ao supervisor fazer o acompanhamento do trabalho. Começou a perceber a existência de muitos clientes negativados. Descobriu que Hélio fazia vendas para clientes da região mudando o e-mail. Motorista levava mercadoria ao cliente e Hélio vendia para um terceiro. Clientes ficaram em vermelho. Ele pagava as duplicatas e chegou a um ponto que ele se perdeu, pois vendia sempre por um valor muito abaixo. Chegou um momento em que não conseguiu mais fazer funcionar esta operação. Hélio acabou confirmando a operação. Ficou sabendo de uma pessoa que comprava dele, um filho de um dono de supermercado. Recuperou parte dos isqueiros.

Motorista era conivente com ele, era ciente da situação e levava as mercadorias. Empresas supostas compradoras não ficavam sabendo das operações porque ele alterava o endereço delas. Ficou com um prejuízo estimado em R\$300.000,00. Motorista tem a obrigação legal de entregar a mercadoria no destino. Como ele não entregava, entregava ao vendedor, entende que ele tinha conhecimento da operação. Fiz isso de forma recorrente, por cerca de 60 vezes. Lá na região somente este motorista agiu assim. Motorista é obrigado a recolher o canhoto com a assinatura do recebedor. Teve de procurar as empresas para evitar que tivessem problemas contábeis e fiscais, já que foram emitidas notas fiscais em nome delas. Não pode dizer qual a vantagem econômica de Leonardo, mas como ninguém faz nada de graça, acha que ele deveria levar alguma vantagem. Ele entregava as notas fiscais e as duplicatas para o HÉLIO. Acredita que havia alguma coisa entre os dois. Ele fazia as entregas. As placas (de veículos) diferentes se explicam por conta do sistema de transbordo, que é uma prática legítima e legal. Se a empresa estiver fechada, ou ele pernoita ou passa à próxima entrega. Não tem a prática de deixar as mercadorias com o representante comercial.

A testemunha de acusação, Rafael Vinicius Mendes Borges, na fase policial, disse que "é quem realizava as compras do Ideal Supermercado, sendo a pessoa de HÉLIO BERNARDINO DA SILVEIRA representante comercial; Que conhece HÉLIO aproximadamente um ano, o qual trabalha na área comercial; Que não se recorda do período, mas comprava produtos de HÉLIO para a empresa às vezes de 15 em 15 dias; Que lembra que no final do ano de 2011 comprou aproximadamente 100 caixas de isqueiros; Que pagou o valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) por cada caixa de isqueiro; Que ficou acordado no ato da compra que HÉLIO mandaria a nota fiscal posteriormente, fato que não aconteceu; Que adquiriu os produtos, pois o preço estava acessível para fazer um promoção no mercado; Que comprou isqueiros de HÉLIO apenas neste período; Que pressionou HÉLIO para que o mesmo lhe mandasse a nota fiscal dos produtos (isqueiros) para que fosse dado entrada dos referidos produtos no mercado, mas HÉLIO preferiu recolher algumas caixas do produto após 10 dias; Que HÉLIO compareceu no mercado acompanhado de seu supervisor e recolheu o restante das caixas de isqueiros; Que pagou para HÉLIO e seu supervisor uma quantia aproximada de R\$ 5.000,00, sendo que dentro destes valores havia um quantia em cheque; PERGUNTADO se tinha conhecimento que HÉLIO estava desviando produtos da empresa TRAVAGIN, RESPONDEU que não; Que nunca teve problemas com HÉLIO, pois ele sempre lhe pareceu uma pessoa idônea; Que relata que acerca de seis meses não trabalha mais no supermercado". Em juízo manteve sua versão. Era comprador e conheceu Hélio como representante. Certa vez comprou uma quantidade de isqueiros, mas devolveu as mercadorias porque vieram sem notas fiscais. Não se recorda bem, mas era um preço acessível a uma oferta. Em algumas semanas o supervisor apareceu para recolher as mercadorias. Quem fez a entrega foi o caminhão da empresa, mas não se recorda quem era. Nesse volume, só comprou essa vez. Mas comprava quinzenalmente. Não era conferente da mercadoria, somente comprador. Este incidente com a nota fiscal só se deu esta vez. Não se recorda da quantidade de mercadoria que foi devolvida. Não se recorda o valor que pagou.

A testemunha de acusação, Sérgio Luiz Fernandes Coimbra, na fase policial, disse que "é supervisor de vendas da firma Travagin & Travagin Ltda e que solicitado pelo proprietário da referida empresa para que o depoente acompanhasse o vendedor HÉLIO, pois estariam desconfiados que o mesmo estaria desviando mercadorias de clientes. Que o depoente descobriu que HÉLIO, em comum acordo com o motorista LEONARDO vendia os produtos da empresa, emitia notas fiscais em nome de clientes e repassava para RAFAEL. Que HÉLIO confessou para o depoente que estavam realmente usando nomes de clientes para efeito de compra e assim passava para terceiros. Na casa de RAFAEL o depoente encontrou 109 (cento e nove) caixas de isqueiro BIC. Que HÉLIO nessa transação ilegal dos isqueiros usou a razão social de 25 clientes, num total de 65 clientes em outros produtos do atacado da referida empresa. Que o depoente solicitou a empresa para que resgatasse os isqueiros na casa de RAFAEL, o que foi feito. Que o depoente ficou sabendo que HÉLIO repassava cada caixa de isqueiro no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), sendo que o custo do produto é mais de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Que HÉLIO ao ser descoberto, entregou ao

depoente diversos documentos, notas fiscais, duplicatas pagas e em aberto, calculado o prejuízo aproximadamente de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Foi constatado que no golpe HÉLIO desviava diversos produtos, tais como papel sulfite, pen-drive, canetas esferográficas, fitas de empacotamento, fita crepe, produtos escolares e office, além dos isqueiros, o principal produto envolvido. Esclarece que as mercadorias eram desviadas da empresa durante a entrega, ou entregava na casa do HÉLIO, ou na casa de RAFAEL, sendo que o motorista era conivente com todo o golpe aplicado, tendo em vista era obrigação do motorista no ato da entrega conferir as notas fiscais e os produtos ao entregá-los ao comprador certo. Que em conversa com RAFAEL, este afirmou que comprava as mercadorias de HÉLIO por um preço bem mais barato, e HÉLIO alegava que comprava as mercadorias com seu CPF, sendo que tal prática era um forma de RAFAEL sonegar os impostos. Que diante disso, a empresa entrou em contato com seus clientes e explicou o caso, cancelando todas as notas fiscais e não deixando ninguém no prejuízo". Em juízo disse que na época era supervisor da empresa e faz seis anos que ele saiu da empresa; tinha um vendedor chamado Hélio e Leonardo era o motorista na época; Hélio faturou alguns pedidos para alguns clientes (não se recorda a quantidade por conta do tempo decorrido) e o motorista repassava para um cliente na cidade de Monte Alegre de Minas; não se recorda se a pessoa que recebia tinha o nome de Rafael, apenas se recorda que o Supermercado Ideal na cidade de Monte Alegre de Minas é quem recebeu os pedidos; quando Hélio foi descoberto, este entregou a Sérgio as notas e as duplicatas; Sérgio detalhou que estava de férias na época e o dono da empresa lhe ligou com suspeitas porque quando foram fazer a entrega no estabelecimento, pessoas do estabelecimento ficaram ligando para não mandar outro motorista, motivo pelo qual a empresa desconfiou que estaria ocorrendo algo fora do comum; Claudinei, seu patrão, ligou e pediu para que Sérgio verificasse a situação, sendo que este pegou tablet e viu que aqueles clientes "estavam em vermelho" (sic), e isto significava que eram clientes devedores; ato contínuo, Sérgio foi até a casa de Hélio e o questionou a situação e, verificou que Hélio possuía anotações, duplicatas e notas e constatou que o motorista entregava os pedidos em Monte Alegre de Minas ou diretamente para Hélio, sendo que este era vendedor da região de Ituiutaba, diante disso, Sérgio pegou todos documentos e repassou para a empresa e. no mesmo dia a empresa mandou um caminhão até Monte Alegre de Minas e Sérgio foi até a casa de um rapaz, que não lembra se este se chamava Rafael, e recolheu 100 (cem) caixas de isqueiro da marca "Bic", todos desviados; relatou que Hélio estava pedindo algumas duplicatas e estava pagando, com isso a empresa Travagin não conseguia ver o cliente devedor, porque Hélio pedia para clientes da região de Ituiutaba, com isso, Hélio perdeu o controle de pagamentos; Sérgio questionou Hélio do motivo de alguns clientes estarem em vermelho em sua planilha e Hélio respondeu que tais clientes iriam pagar amanhã; Sérgio então retornou à empresa informando a situação ao seu superior dizendo que precisariam resolver a situação fiscal desses clientes; os motoristas que faziam as entregas eram Leonardo e uma pessoa chamada Aguinaldo; quando não dava tempo de fazer todas as entregas para o destino, o caminhão voltava para Uberlândia e retornaria na próxima entrega; faziam entregas duas vezes por semana; quando não dava tempo de fazer todas entregas, não era norma da empresa que as entregas pendentes ficassem na responsabilidade do vendedor da região, pois este é autônomo e o correto seria ele retornar ao transbordo e na próxima entrega voltar a entregar ou dormir no local; não sabe se Leonardo era registrado pela empresa ou prestador de serviços; tinha acesso às vendas de Hélio; ele quem contratou Hélio; Hélio foi o primeiro vendedor contratado da região de Ituiutaba; não sabe informar sobre um e-mail direto da empresa citado a respeito de uma autorização de uma entrega divergente de um cliente para entregar em outro local.

A testemunha de acusação, Luis Antonio Borges, na fase policial, disse que "é proprietário do Ideal Supermercado, localizado nesta cidade; Que seu filho RAFAEL trabalhava no estabelecimento na função de comprador; Que conhecia o representante comercial HÉLIO BERNARDINO acerca de 4 a 5 anos; Que pelo que sabe seu filho comprou várias vezes produtos da empresa TRAVAGIN, empresa que HÉLIO representava; Que RAFAEL fez cotação de isqueiros, onde a empresa TRAVAGIN ganhou; Que os

produtos foram entregues, porém a nota fiscal não; Que não sabe dizer se os produtos ficaram no mercado muito tempo estocados, mas os produtos foram devolvidos, em virtude da nota fiscal não ter sido enviada pela empresa TRAVAGIN; Que a respeito dos fatos ocorridos o depoente tomou conhecimento após os fatos terem sido resolvidos por RAFAEL; Que pelo que sabe RAFAEL comprou os produtos (isqueiros) pelo valor de mercado; Que posteriormente tomou conhecimento que HÉLIO estava desviando mercadorias da empresa TRAVAGIN". Não foi ouvido em juízo. A testemunha de defesa Danilo Pereira Peixoto, em juízo, disse que trabalhou na Travagin como motorista em janeiro e fevereiro de 2012; dirigia caminhão da empresa; atuava na região de Goiás; na época em que trabalhava era autorizado a deixar as mercadorias com os representantes quando não encontravam os clientes; não soube da acusação; chegou a ir a Monte Alegre fazer a retirada de uma mercadoria; retirou a mercadoria em uma residência; não se recorda quantidade de mercadoria retirada; foi sozinho e lá existiam duas pessoas; era um bom volume de caixas de isqueiro (aproximadamente cinquenta caixas); pela sua experiência, mercados pequenos não compram aquela quantidade de isqueiros; pela quantidade de caixas que buscou, era difícil levar no carro; nessa quantidade de mercadorias nunca deixou mercadorias com o representante da empresa.

A testemunha de defesa Aguinaldo Ismar de Oliveira, em juízo, disse que era motorista contratada da empresa, mas em outra região; trabalhou lá entre 2010 e 2012; conheceu Leonardo na empresa. Leonardo era terceirizado. Ele trabalhava no caminhão dele. Não ficou sabendo das acusações, pois não conviviam muito. Em algumas vezes (poucas vezes) deixou a mercadoria com o representante da empresa na região; não era prática da empresa, falavam diretamente com o vendedor. Já transportou mercadoria sem nota fiscal; havia uma folha em branco com as anotações da mercadoria; era esporádico isso. Essa entrega diretamente o vendedor, neste volume, não acontecia em sua região. Toda a descrição do endereço de entrega conferia com o nome do estabelecimento.

LEONARDO CLEBER OLIVEIRA, em declarações perante a autoridade policial, disse que "perguntado se trabalhou na empresa Travagin e Travagin Ltda, respondeu que sim, por aproximadamente 1 ano e 08 meses; e que isso se deu no ano de 2010; Que o declarante disse que prestava serviço de motorista/entregador; Que perguntado se conhece a pessoa de nome Hélio Bernardino da Silveira, respondeu que sim que era o vendedor da região de Ituiutaba-MG; Que perguntado se o declarante tinha conhecimento que HÉLIO utilizava o cadastro de clientes da empresa para efetuar compras, respondeu que não; Que perguntado se essa atitude ocorria com a conveniência do declarante, respondeu que não, que não participou de tal ação; Que perguntado se o declarante fazia a entrega das mercadorias para a pessoa de nome Rafael, filho do proprietário do Supermercado Ideal, respondeu que duas vezes o declarante fez entrega para essa pessoa, com autorização do supervisor de vendas de nome Sérgio; Que perguntado se tem conhecimento que HÉLIO alterou o endereço eletrônico dos clientes para que não recebessem as cópias das notas fiscais de compra dos produtos, respondeu que não; Que perguntado se o declarante tinha conhecimento que o vendedor estava desviando mercadorias, respondeu que não. Que perguntado o valor que Hélio vendia as mercadorias, respondeu que não tem conhecimento sobre isso; Que o declarante disse que não tem participação com o golpe aplicado por Hélio e que não era conivente com essa situação; Que perguntado se quando o motorista fazia a entrega se conferia a nota fiscal, produtos, entregando ao comprador certo, respondeu que sim, mas que muitas vezes conferia o volume apenas por não ter contato com o produto que estava dentro de caixas; Que perguntado sobre o aceite da mercadoria (comprovante de recebimento) se era ele quem recolhia, respondeu que as vezes sim, as vezes era o próprio vendedor; Que o declarante disse que pegava o comprovante sempre na entrega posterior; Que perguntado se o declarante fez adulteração do canhoto ou ficou sabendo que os mesmos estavam adulterados, respondeu que desconhece tal fato; Que sobre os fatos é o que tem a dizer". Em juízo manteve sua versão. Disse ser inocente. Era autorizada as mercadorias na casa do vendedor quando não terminava as entregas. Sérgio, supervisor, autorizou a primeira vez (disse para auxiliar o vendedor); nas outras vezes nem ligou mais. Hélio morava em Ituiutaba. Mesmo pedidos de cidades vizinhas

deixava na casa de Hélio. Conheceu Hélio na empresa. Não sabe como Hélio fazia para distribuir as mercadorias. Das 283 entregas só acionou a empresa uma só vez. Nunca dirigiu caminhão da empresa. Não entregou mercadorias de outros clientes no Mercado Ideal.

A negativa do réu não convence. Foram inúmeras entregas, não uma ou outra. E em desconformidade com as instruções dadas pela empresa.

As diversas placas de veículos foram bem explicadas pela vítima, a qual apontou o sistema de transbordo que sua empresa adotava.

Ademais, o montante de mercadorias deixados com o representante legal mostrou-se, em volume físico absolutamente destoante de qualquer prática comercial.

Tais circunstâncias não deixam dúvidas de que a conduta (tipo objetivo) provada pela acusação era dolosa (tipo subjetivo) e integrava um plano criminoso (concurso de pessoas) para auferir vantagem financeira lesando a Travagin e Travagin Ltda.

Não há qualquer óbice ao direito de punir do estado.

A análise da prescrição é feita sobre cada fato típico de forma isolada, conforme art. 119 do Código Penal. Não se conta, portanto, o acréscimo decorrente da continuação. Aliás, é esse o espírito do enunciado 497 da Súmula do STF:

Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Os fatos imputados estão tipificados no art. 171 do Código Penal, com previsão de pena máxima de cinco anos de reclusão.

Considerados isoladamente, a prescrição dá-se em 12 anos conforme inciso III do art. 109 do Código Penal.

Tendo o início dos fatos se dado em agosto de 2011 (art.111, inciso I, do Código Penal), a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo até o recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal) (§1º do art. 110 do Código Penal) só ocorreria a ocorrer em agosto de 2023.

Configurado, assim, o delito de estelionato (topo do artigo 171 do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.
É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vitoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Na análise das circunstâncias judiciais vê-se que a culpabilidade concreta pelo tamanho da lesão ao bem jurídico é imensa, ainda mais considerando as condições da vítima e o contexto social desta comarca, razão pela qual fixo a pena-base no seu máximo legal.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa. Ausentes causas de diminuição da pena; o único aumento é relativo à continuidade. Entre os delitos vê-se uma homogeneidade no modo de agir, tempo e

local das execuções, incidindo a disciplina do art. 71 do Código Penal, com a fração de aumento aplicada no máximo (2/3) em razão do elevadíssimo número de repetições.

Considerando o montante de pena as circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, o regime inicial adequado é o fechado. Todavia, diante da manifestação do Ministério Público e do que dispõe o art. 3º-A do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto.

Por conta da forte negativa das circunstâncias judiciais é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos, bem como sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR LEONARDO CLEBER OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de oito anos e três meses, em regime inicial aberto, bem como a 600 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas no topo do artigo 171, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 2 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA